

1500481-68.2020.8.26.0621

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCAS GARBOCCI DA MOTTA

Comarca: Aparecida

Foro: Foro de Aparecida

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 01/09/2022

... que as drogas eram destinadas ao tráfico. Que o local é conhecido pela prática de tráfico de entorpecentes.

Em interrogatório, o réu Ismael de Oliveira Correia apresentou versão dizendo que: Que os fatos são verdadeiros. Que as drogas eram suas e destinadas ao tráfico, negando tão somente a posse do simulacro de arma de fogo.

Já foi condenado antes por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Aparecida

Foro de Aparecida

1ª Vara

Av. Padroeira do Brasil, 180, ., Aroeira - CEP 12570-000, Fone: (12) 3105-2331,

Aparecida-SP - E-mail: aparecida1@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500481-68.2020.8.26.0621

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 1279/20/201 - DEL.POL.APARECIDA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ISMAEL DE OLIVEIRA CORREIA

Aos 01 de setembro de 2022, às 13:30h, na sala de audiências da 1ª Vara do Foro de Aparecida, Comarca de Aparecida, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). LUCAS GARBOCCI DA MOTTA, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes. Presente a representante do Ministério Público Dra. Paloma Sanguiné Guimarães. Presente o réu ISMAEL DE OLIVEIRA CORREIA, qualificado nos autos, e seu defensor (Gilberto Gomes Mantovani). Presente as testemunhas acusatórias Fabio Henrique Oliveira e Priscila de Almeida Paiva, qualificadas nos autos. Consta que o réu e seu defensor mantiveram conversa privativa antes da instalação da audiência. A seguir, foram ouvidas as testemunhas presentes e interrogado o réu, tendo as inquirições sido realizadas por meio de gravação audiovisual. O conteúdo captado pelo registro audiovisual ficou armazenado em meio magnético e se encontra juntado aos autos. A seguir, pelo MM. Juiz foi declarada encerrada a instrução, passando-se aos debates orais que foram realizados também por meio de gravação audiovisual. Pelas partes foi dito que renunciavam de recorrer da sentença proferida. Tendo em conta se tratar de processo digital, as partes concordam que os respectivos termos sejam assinados somente pelo MM. Juiz.

DELIBERAÇÃO: Ante a renúncia do Ministério Público, defesa técnica e réu,

certifique-se o trânsito em julgado. Segue sentença adiante:

O Ministério Público denunciou ISMAEL DE OLIVEIRA CORREA, já qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei de Drogas c.c. o artigo 61, II, j, do Código Penal, sob alegação de que "no dia 25 de junho de 2020, por volta das 19h12, na Rua Joaquim Bento, via pública, próximo ao numeral 490, Frei Galvão, na cidade de Potim, ISMAEL DE OLIVEIRA CORREIA, qualificado às fls. 23, trazia consigo, para fins de tráfico, drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, devidamente apreendidas (fls. 10/11) e periciadas (fls. 15/17 e 63/65)." (fls. 74/75).

A denúncia foi recebida em 09 de outubro de 2020 (fls. 77/78).

Em análise do flagrante, a prisão foi convertida em liberdade provisória (fls. 44/46).

O réu apresentou resposta à acusação às fls. 115/116.

Folha de Antecedentes às fls. 139/141.

O acusado ofereceu Defesa prévia onde pugnou pela absolvição sumária e, quanto ao mérito, irá apresentar seus argumentos em alegações finais.

Em audiência de Instrução e Julgamento, foram ouvidas as testemunhas e, ao final, interrogado o réu.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais.

Enfim, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, a qual se destina a apurar a responsabilidade penal do réu pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

O feito encontra-se em ordem. Não há preliminares a dirimir. Presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da ação e os pressupostos processuais. Portanto, pertinente a análise do mérito da causa.

A materialidade do delito acha-se consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudos de constatação e de exame químico-toxicológico (fls. 63/65), bem como pelas demais provas orais produzidas nos autos, sendo certa a autoria.

A autoria, por sua vez, é certa e indubitosa.

A testemunha arrolada pelo Ministério Público, policial militar Fábio Henrique Oliveira, declarou em juízo que:

Que estavam em patrulhamento pela cidade de Potim, no cruzamento com a Joaquim Pena. Que avistaram um indivíduo mexendo na parede, nos tijolos. Que o acusado tentou fugir da abordagem. Que localizaram com o acusado um pequeno plástico que continha os entorpecentes apreendidos. Que voltaram ao local onde ele estava mexendo e localizaram um simulacro de arma de fogo. Que o pote com os entorpecentes estava na sua mão. O dinheiro estava com ele. Que o acusado não deu qualquer explicação. Que o acusado morava longe do local dos fatos. Que não se recorda se ele admitiu a posse dos entorpecentes.

A testemunha arrolada pela acusação, policial militar Priscila de Almeida Paiva, narrou em juízo que:

Que estavam em patrulhamento pelo Potim. Que avistaram o indivíduo, que estava de costas. Que ao ver a viatura chegando perto, ele tentou fugir. Que ele foi abordado. Que tinha um potinho na mão dele, com os entorpecentes. Que não se recorda onde estava o dinheiro. Que ele estava bem próximo de um muro ali perto. Que o local é ponto de tráfico. Que fizeram uma varredura pelo local, e encontraram um simulacro perto de onde ele no muro estava. Que o simulacro estava no muro, bem onde ele estava. Ele estava ao lado do muro. Que ele estava mexendo no muro. Que quando ele via a viatura ele correu. Que ele estava virado de frente para o muro. Ele negou a posse das drogas. Que ele admitiu que a droga era dele. Que o potinho com as drogas estava na sua mão. Que ele admitiu que as drogas eram destinadas ao tráfico. Que o local é conhecido pela prática de tráfico de entorpecentes.

Em interrogatório, o réu Ismael de Oliveira Correia apresentou versão dizendo que: Que os fatos são verdadeiros. Que as drogas eram suas e destinadas ao tráfico,

negando tão somente a posse do simulacro de arma de fogo.

Já foi condenado antes por tráfico de drogas, mas está em grau de recurso. Ficou algemado no bar. Os policiais voltaram do local com as drogas, mas não eram sua. Disse que foi confundido com o traficante, pelas mesmas vestes.

No tocante à idoneidade de depoimentos de Policiais Militares, mister ressaltar que, na condição de servidores públicos, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com a observância aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto, qualquer pessoa há de merecer, até prova em contrário, inexistente nos autos.

Ressalte-se, por oportuno, que os policiais não estão impedidos de depor pela legislação processual pátria e o fato de serem servidores comprometidos com a aplicação da lei, repressão e combate ao crime, não retira a força de suas palavras. Pelo contrário, suas palavras têm pleno crédito até que prova manifesta em contrário exclua a presunção.

Nesse sentido:

“Os policiais não estão impedidos de depor. Seus depoimentos têm o mesmo valor que outro qualquer. Há dispositivos expressos no CPP determinando que a polícia deverá colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias (art. 6º, III) e que toda pessoa poderá ser testemunha (art. 202). O só fato de ter sido a prova acusatória baseada em depoimentos prestados por policiais que procederam a prisão em flagrante não autoriza absolvição” (TJSP - AC - Rel. Carlos Bueno - RT 654/278 e RJTJSP 125/563).

“Os depoimentos de policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar seus agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas” (TJRJ - AC - Rel. Synésio de Aquino - RDTJR 7/287).

Nesta senda:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.” (Habeas Corpus Nº 74.608-0, STF, Relator Min. Celso de Mello, DJU 11.4.97, p. 12.189, in TACRIM - As mais recentes decisões nº 5, Jun/97, p.07

“Os depoimentos de policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar seus agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas” (TJRJ - AC - Rel. Synésio de Aquino - RDTJR 7/287).

Portanto, a prova trazida pelos policiais tem o condão de conduzir a condenação do acusado, tendo em vista que os depoimentos são coesos, lógicos e sequenciais, além de trazerem detalhes a respeito dos fatos ora apurados. Ademais, não há que se falar em contradições nos depoimentos das testemunhas de acusação, uma vez que não entraram em contradição em momento algum.

Além disso, é esse o entendimento dos Tribunais:

“Pequenas dissonâncias na prova oral não têm o condão de fazer esboçar o arcabouço probatório. O importante é constatar-se a concordância nos pontos essenciais, desprezando-se eventuais discrepâncias nos pontos secundários que são frutos da imperfeição do psiquismo humano” (JUTACRIM, vol. 95/26, rel. Segurado Braz).

“O importante é como nos diz DELLAPIANE, verificar se embora descorando dos detalhes mínimos concorra a final nos pontos essenciais, nas circunstâncias mais importantes do fato que cada uma, isoladamente reconstituiu” (Nova Teoria da Prova - 2ª ed., Ed. Konfino, 1958 - pág. 145).

Ora, como se vê, a versão trazida pelos policiais militares que efetuaram a prisão

em flagrante do acusado é lógica e coesa, não trazendo quaisquer elementos que a ponham em cheque. Assim, nada há que se discutir quanto à forma como se deram os fatos.

Ambas as testemunhas confirmaram, de modo coerente e lógico, confirmaram que o réu foi flagrado quando trazia consigo substâncias que posteriormente foram confirmados como entorpecentes, sem autorização legal.

Eles afirmaram, com veemência, que quando estavam em patrulhamento pela região dos fatos, região já conhecida pelo tráfico de drogas, quando visualizaram o acusado ISMAEL em atitude suspeita, ocasião na qual decidiram por abordá-lo e encontraram com ele os entorpecentes descritos no auto de exibição e apreensão.

- Quanto ao tráfico de entorpecentes:

Com relação ao tráfico, calha ressaltar, por oportuno, que os delitos previstos nos artigos 33 e 28 da Lei nº 11.343/06 restam consumados sempre que a conduta fática do agente se ajusta com perfeição a um dos comportamentos delineados pelos dois dispositivos legais.

"Para caracterização do tráfico de entorpecentes não é indispensável a prova do ato de comércio, podendo ser ele deduzido de elementos variados como as circunstâncias da prisão, a quantidade do entorpecente, o local da infração etc." (TJRJ - rel. ADOLPHINO RIBEIRO - RDTJRJ 20/310).

No §2º, artigo 28, da Lei de Tóxicos, está disposto que "Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente".

Analisados os aspectos referidos, que devem necessariamente nortear a aferição do juízo em relação à mercancia ou não do entorpecente, é evidente que a droga encontrada destinava-se ao tráfico,

Cabe citar que a venda propriamente dita da droga não é elemento indispensável para a configuração da traficância, tendo em vista consistir o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n.º11.343/2006) em tipo penal misto alternativo, bastando, para a configuração do aludido delito, a prática de qualquer uma das 18 ações tipificadas (importar, exportar, remeter preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar), dispensada a prova do ato da mercancia em si, perfilhando desse mesmo entendimento a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. TRÁFICO INTERNACIONAL DROGAS. EXPORTAR OU REMETER DROGA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 528. (...) O crime de tráfico de drogas é considerado de ação múltipla ou tipo misto alternativo, em que a consumação ocorre com a incidência de qualquer dos núcleos. (STJ, CC 146.393/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJ e 01/07/2016)

Nesse sentido, a jurisprudência:

"Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, 'contrario sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente." (RT 584/347).

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o intuito da traficância pode ser inferido pela quantidade, forma de acondicionamento da droga, comportamento do representado logo antes ou no momento da apreensão, a existência de outros elementos referentes à venda, etc.

Nesta senda:

"A natureza altamente lesiva e a quantidade de porções da droga capturada, somadas à apreensão de apetrechos geralmente utilizados no preparo e disseminação de tóxicos, bem como de certa quantia em dinheiro, são fatores que indicam

envolvimento maior com a traficância, autorizando à preventiva." (HC 323.748/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2015, REPDJ e 05/10/2015, DJ e 28/09/2015).

Quanto ao destino das droga apreendidas, não se discute que os entorpecentes apreendidos destinavam-se ao nefando tráfico. A diversidade das drogas apreendidas, a maneira como estavam acondicionadas, bem como a as condições de tempo e lugar em que o acusado foi abordado, além das declarações dos policiais, denunciam o referido comércio.

Além do mais, ouvido em juízo, o réu confessou a prática do delito. Sobre a grande importância da confissão judicial, de acordo com Adalberto José Queiroz Telles de Camargo Aranha afirma que, por presumir-se livre de vícios da inteligência e vontade, tem ela valor absoluto e serve como base condenatória ainda que seja o único elemento a incriminar o réu e só perderá sua força se desmentida pelas provas restantes (Da prova no Processo Penal, São Paulo: Ed. Saraiva, 7ª ed., 2006, p. 122). Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência: "Ora, a confissão judicial, como se sabe, é elemento importantíssimo de prova, que somente pode ser afastado por circunstâncias excepcionais que tornem duvidoso seu valor. Se, ao contrário, é segura, coerente e sem desmentidos, além de encontrar apoio nos demais elementos de convicção existentes nos autos, o que cumpre é dar valor absoluto a esta prova.

Nesse sentido já se decidiu: "A confissão judicial, sem margem para divagações doutrinárias, ou tertúlias hermenêuticas, constitui seguríssimo elemento de convicção. Apenas incomum circunstância, aqui não vislumbrada, que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua recusa. Assim, se o acusado admite, sem explicações ou justificações plausíveis, a verdade do gesto criminoso que lhe vem atribuído, não há como fugir à proclamação da procedência da pretensão punitiva deduzida.

(Apelação Criminal nº 297.351-3/5, 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, rel. Des. Canguçu de Almeida, julgado em 20/10/2003)." (AC2018.0000360351, 11ª Câmara de Direito Criminal do TJ/SP, rel. Alexandre Almeida, 16 de maio de 2018). De acordo com a Doutrina: "É sumamente tranquilizador para a consciência do juiz ouvir dos lábios do réu uma narrativa convincente do fato criminoso com a declaração de tê-lo praticado, consistindo um verdadeiro 'raio de luz que ilumina de jato todos os escaninhos dos crimes ocultos, dissipa as dúvidas, orienta as ulteriores investigações e conforta de um só passo os escrúpulos do juiz e as preocupações de justiça dos homens de bem" (HÉLIO TORNAGHI, Curso de Processo Penal, vol. 01, págs. 378/379). Tem-se que a confissão não é elemento isolado nos autos, uma vez que foi corroborada pelo restante do conjunto probatório. Neste sentido: "A confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos pode levar à condenação do acusado. Já se tem decidido, por isso, que a confissão judicial é prova para a condenação, máxime quando compatível com a materialidade do delito e realizada na presença do defensor ou corroborada por depoimentos, mesmo do inquérito policial". (Júlio Fabbrini Mirabete - Processo Penal - ed. Atlas, 8ª edição, pág. 288). É dizer: a confissão tem valia, ainda mais porquanto corroborada pelo restante da prova produzida, sendo apta a fundamentar a prolação de decreto condenatório, não havendo nos autos a comprovação da existência de nenhum vício de vontade que pudesse determinar a sua desconsideração.

Certo é que, além da harmônica prova oral acusatória, as espécies das substâncias entorpecentes apreendidas, a forma como acondicionadas e as circunstâncias da prisão, tornam evidente que a droga destinava-se ao consumo de terceiro. Tais circunstâncias constituem elementos relevantes para a configuração do crime de tráfico de entorpecentes.

Portanto, o acusado realizou conduta típica, antijurídica e punível, em face de sua culpabilidade, impõem-se a condenação e a pena, eis que em seus benefícios não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

Procedente a ação penal, passo a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria, em observância as diretrizes do artigo 59, do Código Penal c.c. art 42 da Lei nº 11.343/2006, note-se que o acusado, quando menor, conta com diversos registros por atos infracionais e, ainda, o que é possível aferir dos autos (fls. 32), ostentando diversos processos de apuração de atos infracionais equiparados a tráfico. Prevê o art. 59 do Código Penal que se

considere, quando da fixação da pena, de várias circunstâncias, dentre as quais a personalidade do agente. Neste esteio, lição de Ney Moura Teles: "personalidade não é um conceito jurídico, mas do âmbito de outras ciências da psicologia, psiquiatria, antropologia e deve ser entendida como um complexo de características individuais próprias, adquiridas, que determinam ou influenciam o comportamento do sujeito" (Direito Penal: parte geral São Paulo: Ed. de Direito 1996 v. II p. 125-126). E, ainda, também a do prof.º Dr. Desembargador Guilherme de Souza Nucci: "a personalidade tem uma estrutura muito complexa. Na verdade é um conjunto somatopsíquico (ou psicossomático) no qual se integra um componente morfológico, estático, que é a conformação física; um componente dinâmico-humoral ou fisiológico, que é o temperamento (...). Na configuração da personalidade congregam-se elementos hereditários e sócio-ambientais, o que vale dizer que as experiências da vida contribuem para sua evolução. Esta se faz em cinco fases bem caracterizadas: infância, juventude, estado adulto, maturidade e velhice" (Código Penal Comentado, 12ª Ed. - São Paulo: RT - 2012 - p. 432). Ainda nesta linha, esclarecedora a lição do Dr. Promotor Cleber Masson que, ao comentar o art. 59 do Código Penal, afirmou que a personalidade do agente "(...) é o perfil subjetivo do réu, nos aspectos moral e psicológico, pelo qual se analisa se tem ou não o caráter voltado à prática de infrações penais" (Código Penal Comentado - 5ª ed. - São Paulo: Método - 2017 - p. 352). Assim, não obstante ter o réu praticado atos infracionais quando adolescente não possa ser considerado como Maus Antecedentes - circunstância judicial distinta, entendo ser plenamente possível que seja levada em conta tal circunstância para a análise de sua personalidade e, com isso, concluir que evidencia-se quadro contundente que assinala a predileção do réu pela senda criminoso. É a orientação do Pretório Excelso: "A avaliação sobre a periculosidade de alguém impõe que se perscrute todo o seu histórico de vida, em especial o seu comportamento perante a comunidade, em atos exteriores, cujas consequências tenham sido sentidas no âmbito social. Se os atos infracionais não servem, por óbvio, como antecedentes penais e muito menos para firmar reincidência (porque tais conceitos implicam a ideia de 'crime' anterior), não podem ser ignorados para aferir a personalidade" (STJ - HC 139.761/SP - rel. Luiz Fux - j. 08.02.2017). Desta forma, não se confundindo antecedentes com personalidade, sendo esta a somatória de vários fatores, dentre os quais a experiência de vida, possível a utilização da vivência infracional do acusado, a qual é farta, para a majoração da pena base, a título de personalidade deturpada. Ademais, o réu é primário e não ostenta Maus Antecedentes desabonadores. Contudo, pelos motivos acima explicitados, valore negativamente sua personalidade. As demais circunstâncias judiciais são normais à espécie de delito. Dessa forma, majoro as penas-base acima dos patamares mínimos legais, fixando-as em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo unitário.

Na segunda fase, forçoso o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa, tendo em vista que o réu contava com menos de 21 anos à época dos fatos e da confissão espontânea, diminuindo as penas para os seus mínimos legais, 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo unitário. Consigno que é inviável as suas reduções aquém destes, considerada o entendimento sumular da Corte Superior (Súmula nº 231 do STJ), razão pela qual mantenho as penas nos seus mínimos legais nesta fase.

Ainda terceira fase, a prova dos autos não é suficiente para comprovar o envolvimento do acusado com organização criminoso, nem para concluir, seguramente, que ela se dedica à prática reiterada do tráfico ilícito de drogas ou outros crimes. É certo que a Nova Lei de Drogas aperfeiçoou a sanção penal ao operar a distinção entre meros mercadores ocasionais, também merecedores de atenção do Estado, dos comerciantes de droga mais estruturados, verdadeiros empresários do tráfico. Distinção reclamada há muito tempo pelos aplicadores do Direito, tem por consequência a menor reprovabilidade da conduta do traficante ocasional e sua pena encontra fundamento e limite com a redução a integrar o tipo penal para os que apresentem as condições subjetivas típicas daqueles que não tenham estruturado envolvimento com o tráfico de drogas. No presente caso, entendo cabível a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 e, considerando a pequena

quantidade de droga encontrada, entendo por bem em reduzir as penas na fração máxima legal de 2/3 (dois terços), diminuindo-as para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, mais o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo legal, suficientes para a reprovação do tráfico de drogas. Ausentes outras circunstâncias que alterem as penas, torno-as definitivas nestes patamares. Tendo em vista a decisão do C. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC nº 111.840/ES, que retirou o caráter de hediondez do tráfico privilegiado e afastou a obrigatoriedade do regime inicial fechado, o regime inicial de cumprimento de pena da investigada será o ABERTO em razão da quantidade da pena aplicada e atento aos critérios dos artigos 33, combinado com o artigo 59, ambos do Código Penal. No mesmo sentido, decidiu a C. Segunda Turma do STF: "Tráfico de entorpecentes: fixação do regime e substituição da pena. Não sendo o paciente reincidente, nem tendo contra si circunstâncias judiciais desfavoráveis (CP, art. 59), a gravidade em abstrato do crime do art. 33, "caput", da Lei 11.343/2006, não constitui motivação idônea para justificar a fixação do regime mais gravoso. Com esse entendimento, a Segunda Turma, após superar o óbice do Enunciado 691 da Súmula do STF, concedeu "habeas corpus" de ofício para garantir ao paciente, condenado à pena de um ano e oito meses de reclusão pela prática do delito de tráfico de drogas, a substituição da reprimenda por duas penas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo juízo das execuções criminais, bem assim a fixação do regime inicial aberto. O Colegiado entendeu que o paciente atende aos requisitos do art. 44 do CP, razão pela qual o juízo deve considerá-los ao estabelecer a reprimenda, de acordo com o princípio constitucional da individualização da pena. (HC 133028/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, 12.4.2016. (HC-133028). Por isso, diante desses argumentos, entendo suficiente para a justa reprimenda a fixação de regime inicial prisional ABERTO.

Embora ciente da nova orientação jurisprudencial, que admite a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, entendo que, no caso, a medida não se mostra suficiente e socialmente recomendada para o caso em tela, haja vista que, a despeito da primariedade e da ausência dos maus antecedentes, o réu possui largo histórico no meio infracional, o que faz com que as circunstâncias judiciais não lhe sejam inteiramente favoráveis, não sendo recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Da mesma forma, entendo por que as circunstâncias do caso, notadamente a personalidade do agente, não autorizam a concessão da suspensão condicional da pena, prevista no art. 77 do Código Penal.

O valor de cada dia-multa será no mínimo legal de 1/30 ao salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em razão das limitadas condições econômicas dos réus (art. 43, da Nova Lei de Drogas).

DISPOSITIVO.

Pelo exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal, passo a CONDENAR o réu ISMAEL DE OLIVEIRA CORRÊA, qualificado nos autos às págs. 9/11, às penas de 1 (um) ano e 8 (meses) de reclusão, em regime inicial ABERTO mais o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo legal, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, aplicado o redutor previsto no seu parágrafo quarto.

Não havendo impugnação específica do laudo pericial, nos termos do despacho inicial, fica autorizada a incineração das drogas apreendidas.

Decreto o perdimento dos bens apreendidos em favor da União.

Arbitro honorários ao(à) advogado(a) nomeado(a) no presente processo no patamar máximo do valor respectivo previsto na tabela de honorários advocatícios do convênio firmado entre OAB/SP e DPESP. Elabore-se a competente certidão de honorários advocatícios.

Condeno o(a) sentenciado(a) também ao pagamento das custas e despesas processuais. Entretanto, lhe concedo o benefício da gratuidade da justiça e determino a suspensão das condenações pecuniárias contidas nesse parágrafo, na forma do art. 98 do Código de Processo Civil.

Havendo recurso de qualquer das partes, independentemente de nova conclusão,

expeça-se imediatamente guia de recolhimento provisória, remetendo-a ao Juízo competente para adequação das condições da prisão.

Após o trânsito em julgado:

Determino a destruição das drogas, inclusive amostras guardadas como contraprova, vinculada à prova destes autos, na forma do art. 72 da Lei n. 11343/06;

Caso exista pena de multa, providencie a serventia, observado o disposto no art.

336, caput, do Código de Processo Penal, o cálculo da pena de multa a pagar, manifestando-se o Ministério Público e a Defesa (Cláusula Décima Primeira, § 25 do Termo de Convênio entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de São Paulo - Convênio n. 003/2016). Em seguida, tornem-me conclusos para homologação (art. 538, § 1º, das NSCGJ);

Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do art. 15, inciso III da Constituição da República e art. 71, § 2º do Código Eleitoral;

Expeça-se a guia de recolhimento definitiva, remetendo-a ao Juízo competente, observando-se em tudo o Comunicado CG 1182/2017;

Lance-se o nome do sentenciado no rol do IRGD;

Ofícios de praxe;

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diligências necessárias. Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa.

Nada mais, saindo os presentes intimados. Nada mais. Eu (Adilson Carlos de Toledo Oliveira), Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

MM. Juiz: (assinatura digital)